

1500880-08.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... tese, passou a ser possível, em sede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim concluo, pois, a despeito de minha total discordância pessoal, sou forçado a reconhecer que o STF considerou inconstitucional a vedação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500880-08.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500880-08.2022.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY MAGALHÃES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 09 de maio de 2022, por volta das 02h40min, na Rua Juruá, nº 33, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, os réus EDINALDO FERREIRA LEITE e WESLLEY MAGALHÃES, agindo em concurso e com unidade de desígnios, guardavam, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 274 porções de maconha, com peso líquido de 465,8g, 202 porções de cocaína, com peso líquido de 108,7g, e 04 porções de crack, com peso líquido de 0,7g, e 06 frascos de lança perfume, drogas estas que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 22, laudo de constatação de fls. 42/44 e laudo definitivo de fls. 153/154.

Denúncia recebida às fls. 155/156. As provas orais e os interrogatórios foram colhidos por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade é expressa pelo laudo toxicológico de fls. 153/154, bem como toda a

prova oral produzida.

Quanto à autoria, tudo indica que há uma tentativa concertada de inocentar o réu Edinaldo (com vários registros criminais), a partir da total confissão dos fatos pelo réu Wesley. A orquestração defensiva, contudo, é desvelada por meio de contradições importantes que vieram a lume.

Às provas.

Inquirido em solo judicial, o policial militar Richard ofertou depoimento no mesmo sentido daquele oferecido na via inquisitiva, à fl. 09.

A testemunha Janaina limitou-se a dizer que trabalhava no bar e que foi embora logo depois de atender Edinaldo, não estando presente no momento da abordagem policial.

Daiane, companheira de Wesley, ouvida como informante, relatou que havia várias pessoas no bar no momento da ação policial; que os policiais invadiram logo após atenderem Edinaldo; que desceu para fechar o caixa, quando os policiais chegaram.

O réu Wesley disse que a droga era sua, destinada à venda; que Edinaldo nada sabia; que Edinaldo havia acabado de chegar quando os policiais entraram.

O inculcado Edinaldo, por sua vez, afirmou que estava em churrasco, quando lhe pediram que fosse comprar mais bebidas; que chegou ao bar e, cerca de 40 minutos depois, os policiais apareceram.

A condenação afigura-se de rigor.

Primeiramente, porque em momento algum os réus afirmaram ter tido desavença anterior com os servidores da ordem realizadores da prisão que, em tese, justificasse desejo de vingança por parte destes. De outra sorte, também não informaram ter recebido pedido ou exigência de vantagem indevida deles. Assim, inexistente fundamento a esvaziar a confiabilidade dos depoimentos dos respeitáveis policiais militares.

Ainda, verifico que Daiane, companheira de Wesley, quando ouvida em juízo, deu versão diversa sobre sua chegada ao bar, em cotejo com a inquirição policial de fls. 15/16. Naquela seara administrativa, havia dito que descera ao bar depois de ter ouvido uma discussão de clientes. Na via judicial, porém, simplesmente disse que desceu para fechar o bar, sem qualquer referência à mencionada discussão.

Digna de nota, também, a visível discrepância acerca do lapso temporal de permanência de Edinaldo no bar.

Wesley afirmou que Edinaldo havia “acabado de chegar” quando os policiais apareceram. O próprio Edinaldo, todavia, relatou encontrar-se no bar havia 40 minutos, antes da chegada dos agentes estatais...

Bastante estranho, também, que nenhum dos demais clientes do bar supostamente presentes ou dos indivíduos que se encontravam no tal churrasco mencionado por Edinaldo tenha sido arrolado como testemunha, presumindo-se, pelo contexto, que seriam pessoas do convívio dos réus.

Passo a dosar as penas.

2. Início pelo réu Wesley.

Na primeira fase, não existe circunstância judicial desfavorável, a recomendar o aumento da pena-base. Isso porque, ao reverso do meu posicionamento, a atual

jurisprudência do STJ não admite que a quantidade e natureza dos entorpecentes sejam ponderadas neste momento e na terceira etapa do critério trifásico.

Na segunda fase, nada a considerar.

Por derradeiro, encontra-se presente a minorante contida no art. 33, par. 4º, pois o réu não ostenta antecedentes negativos ou outra circunstância que sugira se tratar de pessoa habitualmente dedicada à criminalidade (embora, a meu juízo, a quantidade dos narcóticos se prestasse a tal finalidade).

Vigora, atualmente, o posicionamento manifestado no REsp 1.887.511/SP, pelo qual se admite que a quantidade/qualidade de drogas seja valorada na modulação da causa de diminuição, desde que não o tenha sido nas fases anteriores. Assim (grifei):

"Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Diretrizes firmadas no EREsp 1.887.511/SP. Uso apenas supletivo da quantidade e natureza da droga na terceira fase da dosimetria. Revisão de posicionamento. Manutenção do entendimento consolidado há anos pelas Cortes Superiores, acolhido no ARE 666.334/AM pelo STF. Expressiva quantidade de droga apreendida. Único elemento aferido. Modulação da causa de diminuição.

Possibilidade.

"'É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.'"

(HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022)

Considerando a enorme quantidade de entorpecentes (486 porções de 4 tipos de drogas), representativa, senão de dedicação habitual ao comércio espúrio, ao menos de reprovabilidade acima do ordinário, entendo que o abrandamento deve montar no patamar mínimo de 1/6. Censura arbitrada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão.

Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da nova Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 416. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo os dias-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

Ao réu Edinaldo.

Tendo em vista a já mencionada quantidade de entorpecentes e, nos termos do sobredito REsp 1.887.511/SP, que tal elemento não será valorado na terceira etapa, elevo a pena-base neste momento em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda fase, conforme fls. 56/70 e 73/76, as execuções penais de nº 01, 02, 03 e 04 foram extintas pelo cumprimento em 20/09/2019. A execução penal nº 05, por sua vez, ainda encontrava-se vigente quando da prisão em flagrante do réu. Trata-se, pois, de multirreincidente e de reincidente específico, pois uma das condenações é pelo crime de tráfico de drogas (execução nº 03).

Diante da significativa pletora de condenações e da recidiva específica, denotativas de devoção habitual à criminalidade, entendo cabível e proporcional a dobra da censura, aqui arbitrada em 11 anos e 8 meses de reclusão.

No estágio derradeiro, nada a pontuar, já que a minorante do art. 33, par. 4º, não pode sequer ser cogitada, diante da reincidência.

Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da nova Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 1.166. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo os dias-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

3. Passo a deliberar sobre o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

Em relação ao réu Edinaldo, a quantidade da pena corporal e a múltipla reincidência conduzem ao regime inicial fechado e à impossibilidade de qualquer benefício penal.

Quanto ao réu Wesley.

Em tese, passou a ser possível, em sede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim concluo, pois, a despeito de minha total discordância pessoal, sou forçado a reconhecer que o STF considerou inconstitucional a vedação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos trazida pelo art. 44 da nova Lei de Drogas. O leading case sobre o tema foi o HC 97.256/RS. Por força de tal decisão, a resolução n. 5, de 2012, do Senado Federal, publicada em 16 de fevereiro de 2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Posteriormente, em mais um de seus controversos julgados, o STF também considerou afastada a natureza hedionda do delito em testilha quando computada a causa de diminuição de pena acima ponderada (HC 118533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, 23.6.2016), de modo a excluir a incidência do art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos.

Assentadas tais premissas (ainda que a contragosto deste sentenciante), entendo que o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade mais adequado é o semiaberto, à luz da quantidade da exprobração e levando em conta a ausência de antecedentes criminais desabonadores.

O quantum do escarmento impede a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, todavia.

4. Ante o exposto:

A) declaro o réu EDINALDO FERREIRA LEITE incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.166 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

B) declaro o réu WESLEY MAGALHÃES incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

5. O réu Edinaldo, que respondeu ao feito preso, assim deve permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que o exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial fechado pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorável. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

"O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade"
(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Quanto ao réu Wesley, expeça-se alvará de soltura clausulado.

6. Determino, ainda, o perdimento do numerário apreendido, ante as fortes evidências de se tratar de dinheiro fruto da traficância espúria (art. 63, par. 1º, Lei de Drogas). Oficie-se.

7. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

8. Custas na forma da legislação estadual.

9. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

10. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

P.R.I.C.

Itapeccerica da Serra, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA